

1500074-11.2022.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cibele Carrasco Rainho Novo

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/06/2022

... que permearam o presente crime de tráfico de entorpecentes, já que existiam fundadas razões do flagrante delito no local, e que, com a entrada no imóvel, se confirmaram.

Aliás, o crime de tráfico de entorpecentes é permanente, possibilitando, assim, a entrada no domicílio do indivíduo enquanto perdurar o estado de flagrância.

Nesse sentido, o E. Supremo Tribunal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

2ª Vara Criminal

Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

1500074-11.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

CONCLUSÃO:

Em 22 de junho de 2022, faço a conclusão destes autos à Exma. Sra. Dra. CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO, MMª. Juíza de Direito Auxiliar desta Comarca. Eu, Assistente Judiciário, digitei.

Processo nº:

1500074-11.2022.8.26.0583

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS AMARAL DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cibele Carrasco Rainho Novo

VISTOS.

VINICIUS AMARAL DOS SANTOS, qualificado nos autos (fls. 21), foi denunciado pela prática do delito tipificado no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, porque, segundo narrativa contida na peça acusatória (fls. 02/04), no dia 18 de janeiro de 2022, por volta das 19h20min, na rua Doutor Geraldo C, nº 140, Jardim Humberto Salvador, nesta cidade e comarca, tinha em depósito, para fins de tráfico, uma porção pesando 122,88 gramas (cento e vinte dois gramas e oitenta e oito decigramas) de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida por "maconha", além de 46 (quarenta e seis) porções, pesando 7,21g (sete gramas e vinte e um decigramas), da substância Erythroxylum coca, na forma petrificada, conhecida por "crack", substâncias entorpecentes capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Durante a fase de inquérito, providenciou-se a confecção e juntada do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 05/06), Termos de depoimentos de testemunhas (fls. 07/08 e 09) e de interrogatório (fls. 11), Boletim de Ocorrência (fls. 13/16), Auto de Exibição/Apreensão (fls. 17/18), fotografias dos entorpecentes apreendidos (fls. 33/40), Laudo de Constatação (fls. 44/46), Pesquisa SIVEC (fls. 48/49), Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 50 e 51) e Pesquisa Fonética (fls. 52).

Realizou-se Audiência de Custódia (Termo a fls. 58/63), ocasião em que houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com a expedição do respectivo mandado (fls. 64/65), devidamente cumprido (fls. 74/75).

Na sequência, em virtude da impetração de Habeas Corpus (nº 2006049-57.2022.8.26.0000 - fls. 89/101), houve a comunicação do indeferimento da liminar (fls. 86/88), advindo aos autos Laudo Pericial atinente à balança de bolso e folha de caderno apreendidas (fls. 112/114), Laudo Definitivo - Exame Químico-Toxicológico (fls. 115/117), Guia de depósito judicial (fls. 119 - R\$45,00), Relatório Final do Inquérito Policial (sob nº 2016346 - fls. 121/124) e Laudo Pericial realizado referente ao aparelho celular apreendido (fls. 153/159).

Oferecida a denúncia (fls. 02/04), o réu foi notificado (certidão a fls. 139) e, por meio de Defensor dativo (fls. 140), ofertou resposta (fls. 143/147), tendo a peça acusatória, após a manifestação do Órgão Ministerial (fls. 150/151), sido recebida em 21.03.2022 (fls. 161), seguindo-se da citação do acusado (fls. 180) e juntada de cópia do documento apreendido (fls. 181), do RG Criminal (fls. 182) e do Auto de Colheita de Material Caligráfico (fls. 190).

Após a análise e manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 316, §único do CPP (fls. 198), realizou-se audiência de instrução, debates e julgamento (Termo a fls. 199/200), procedendo-se, por gravação audiovisual, à inquirição de quatro testemunhas e ao ato de interrogatório.

Na sequência, com a juntada do Laudo de Exame Caligráfico (fls. 205/213) e o encerramento da fase instrutória (fls. 223), o Ministério Público, em memoriais finais (fls. 226/233), pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia e, no que tange a dosimetria da pena, pela inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas e pela fixação do regime inicial fechado.

A Defesa, por sua vez, em memoriais finais (fls. 236/275), pleiteou, preliminarmente, o desentranhamento das provas ilícitas, ante a nulidade da busca pessoal e domiciliar, com a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso II do CPP, e, no mérito, alegando insuficiência de prova, requereu a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de porte para consumo pessoal. Ponderando a possibilidade de condenação, pugnou pela fixação da pena base no seu mínimo legal, pela aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas, pela fixação do regime inicial aberto, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, terminando por requerer a concessão do direito de recorrer em liberdade.

É a síntese do necessário.

Passo a fundamentar e decidir.

Constato que o processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar e, estando presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais, imperioso o julgamento do mérito.

E no mérito, procede a pretensão acusatória, eis que demonstrada a autoria e materialidade do delito imputado (artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06), face ao Auto de Prisão em Flagrante (fls. 05/06), Termos de depoimentos de testemunhas (fls. 07/08 e 09) e de interrogatório (fls. 11), Boletim de Ocorrência (fls. 13/16), Auto de Exibição/Apreensão (fls. 17/18), fotografias dos entorpecentes apreendidos (fls. 33/40), Laudo de Constatação (fls. 44/46), Laudo Pericial atinente à balança de bolso e folha de caderno apreendidas (fls. 112/114), Laudo Definitivo - Exame Químico-Toxicológico (fls. 115/117), Guia de depósito judicial (fls. 119 - R\$45,00), Relatório Final do Inquérito Policial (sob nº 2016346 - fls. 121/124), cópia do documento apreendido (fls. 181), Auto de Colheita de Material Caligráfico (fls. 190), Laudo de Exame Caligráfico (fls. 205/213) e prova oral, colhida sob o crivo do contraditório (fls. 199/200).

Vejamos.

Por primeiro, incontroverso nos autos, à vista do Laudo de Exame Químico-Toxicológico elaborado (fls. 115/117), tanto a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (Auto de Exibição e Apreensão a fls. 17/18), uma vez que "...DETECTADA presença da substância COCAÍNA", "...DETECTADA presença da substância COCAÍNA" e "...DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC)", quanto as suas quantidades ("Massa Líquida: 0,35 grama(s)", "Massa Líquida: 6,86 grama(s)" e "Massa Líquida: 122,88 grama(s)").

Por segundo, no que tange à propriedade e destinação da aludida droga, diante das provas colhidas e circunstâncias dos fatos, evidencia-se que esta pertencia ao réu e se destinava ao tráfico ilícito de entorpecentes, figura prevista no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06.

Isto porque, em harmonia com o depoimento prestado na fase policial (fls. 07/08), a testemunha Jefferson Martins da Costa Junior, policial militar, em Juízo (fls. 199/200), narrou que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento pelo bairro Humberto Salvador e, como já possuíam conhecimento de algumas denúncias (rua e numeral), adentraram na via e visualizaram um indivíduo, posteriormente identificado como Vinicius (acusado), o qual, ao vislumbrar a viatura, tentou retornar rapidamente para sua casa, contudo, foi possível abordá-lo antes, sendo que, em busca pessoal, foi localizado um celular e duas pedras de "crack", prontas para venda, e, ainda durante a abordagem, sua mãe chegou no local, vindo a franquear a entrada para busca na residência, oportunidade em que fora localizado, na frente da casa, perto de umas plantas, um pote com quarenta e quatro pedras de "crack", embaladas da mesma forma que as porções encontradas na posse do acusado, e, ao fundo da residência, em um porão, dentro de uma caixa, onze pedaços de "maconha" e uma quantia esfarelada, e, ainda, uma balança de precisão e um papel.

Contou a testemunha policial, também, que foi localizado a quantia de R\$45,00 (quarenta e cinco reais) e, a pedido do Ministério Público, após ter sido colocado na tela o documento com anotações (folha de papel), a testemunha reconheceu-o como o apreendido na ocasião.

No mesmo sentido e em simetria com o depoimento da testemunha Jefferson, a testemunha Aristóteles José de Silva de Almeida, também policial militar, em Juízo (fls. 199/200), elucidou que, em busca pessoal, foi localizado, no bolso do lado direito do acusado, duas pedras de "crack", embaladas para venda, e, após franqueada a entrada na residência por sua genitora, na frente da casa, dentro das flores, um pote plástico contendo quarenta e quatro pedras de "crack", com a mesma embalagem da droga encontrada no bolso de Vinicius, bem como, no fundo da residência, em um porão, onze pedaços de "maconha", uma balança de precisão, algumas porções esfareladas dentro de uma caixa e um papel, que, diante da circunstância, poderia ser de anotações do comércio espúrio, e que restou reconhecido pelo depoente em Juízo, após pedido do Órgão Ministerial, tendo

elucidado, por fim, que haviam recebido denúncias do tráfico de drogas, pelo sistema da Polícia Militar (190) e de usuários, tanto em relação ao endereço, como ao nome do acusado.

As testemunhas Matheus Amaral dos Santos e Paulo Henrique Amaral, irmãos do acusado, as quais, em razão da condição parental, nos termos do artigo 208 do Código de Processo Penal, foram ouvidas sem prestar o compromisso previsto no artigo 203 do mesmo diploma legal, em Juízo (fls. 199/200), informaram que estavam na residência na data dos fatos, no entanto, não presenciaram o momento da abordagem, pois estavam dentro da casa, nem a localização dos entorpecentes, pois foram colocadas do lado de fora do imóvel pelos policiais militares, afirmando que suas mãe chegou no local depois da polícia adentrar na residência.

Por seu turno, o acusado, durante seu interrogatório judicial (fls. 199/200), negou a prática do crime que lhe é imputado, informando que apenas a “maconha” era sua, bem como, a posse dos demais entorpecentes, da balança de precisão e do papel com anotações apreendidos.

Nesse aspecto, diante da divergência instaurada, pontuo que não há nos autos qualquer indício idôneo de que as aludidas testemunhas (policiais militares), que são agentes públicos, tenham mentido, tampouco de que possuam motivos para, falsamente, imputar a prática do crime ao acusado.

Para ilustrar o convencimento, trago à luz recentes julgados de nossa Corte de Justiça Paulista:

“APELAÇÃO. DEFESA. FURTO SIMPLES TENTADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. Artigo 155, §1º, c.c o 14, inciso II, ambos do Código Penal. Sentença de procedência. Mérito. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. O valor do depoimento testemunhal de agentes públicos, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Declaração da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Substanciosa confissão colhida em juízo. Majorante do repouso noturno bem delineada. Dosimetria. Maus antecedentes caracterizados. Circunstância atenuante da confissão espontânea reconhecida nos termos da Súmula n. 545 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sem influência na expressão aritmética da pena. Multirreincidência que impede a compensação integral entre as circunstâncias. Fração de diminuição mínima pela tentativa mantida, pois em consonância com o iter criminis percorrido pelo agente. Regime inicial semiaberto bem fixado. Artigo 33, §§2º, alínea c, e 3º, do Código Penal. Súmula n. 269 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM INFLUÊNCIA NA EXPRESSÃO ARITMÉTICA DA PENA.”
(negritei)
(Apelação Criminal 1500507-59.2020.8.26.0300; Relator (a): CAMARGO ARANHA FILHO; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 06/06/2022).

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 se as circunstâncias que envolvem os fatos, dentre elas a a quantidade de drogas, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. Recurso não provido.”
(negritei)
(Apelação Criminal 1500037-95.2021.8.26.0040; Relator (a): LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 03/06/2022).

Ademais, a significativa quantidade de drogas, a diversidade e a forma como estavam acondicionadas – 02 duas porções de “crack” na posse do acusado, que estava defronte a residência, e 44 (quarenta e quatro) porções de “crack” escondidas dentro do imóvel, com a mesma embalagem, além de vários pedaços de maconha – (Auto de Exibição e Apreensão a fls. 17/18; fotos a fls. 33/40), somado a apreensão de balança de precisão e uma folha de papel, a qual com anotações de nomes e números, encontrada junto com o entorpecente, constituem fortes indicativos do propósito de comercialização.

Além do mais, realizada perícia no documento apreendido (Laudo a fls. 205/213), o qual contém vários nomes e números, tudo a indicar o controle do tráfico, representando os números os valores devidos pelos usuários (documento a fls. 181), e apesar do acusado, em Juízo (fls. 199/200), ter negado a existência do documento em sua residência, assim como, a autoria da letra nele aposta, restou apurado pela ilustre Perita que a escrita partiu do punho do acusado (“Dessa forma, é possível inferir que o conteúdo da folha escrita e apresentada para análise, presente na figura 2, partiram do punho do autor ora questionado, Vinícius Amaral dos Santos, como apresentado em alguns exemplos nas figuras 4 e 5 a seguir.” – “ex vi” fls. 210).

Outrossim, não merece acolhimento o pedido de nulidade da busca pessoal, por ausência de motivação idônea, pois, conforme relatado pelos policiais militares, além das denúncias recebidas em relação ao crime de tráfico na residência de Vinícius, este, na data dos fatos, ao visualizar a viatura policial, tentou evadir-se da abordagem, de forma a justificar, assim, a conduta por eles adotada, que, como visto, certa, pois, no bolso da bermuda do acusado, fora localizado duas pedras de “crack” e, posteriormente, dentro da residência, várias porções da mesma substância, embaladas da mesma forma, além, como já dito, de outras porções de “maconha”, balança de precisão e um documento com anotações a indicar o controle de vendas, restando, pois, configurada a fundada suspeita amparadora da diligência (artigo 244 CPP).

No mais, também não merece prosperar o pedido deduzido pela Defesa, voltado ao reconhecimento da tese de invasão domiciliar, com a consequente nulidade das provas obtidas, uma vez que, além de não haver prova cabal sobre a aventada ausência de anuência à diligência de vistoria na casa, já que as testemunhas divergem nesse sentido e, estranhamente, inexistente qualquer declaração da genitora do réu nesse sentido, a ação policial justifica-se plenamente diante da apreensão da grande quantidade de droga e de todas as circunstâncias que permearam o presente crime de tráfico de entorpecentes, já que existiam fundadas razões do flagrante delito no local, e que, com a entrada no imóvel, se confirmaram.

Aliás, o crime de tráfico de entorpecentes é permanente, possibilitando, assim, a entrada no domicílio do indivíduo enquanto perdurar o estado de flagrância.

Nesse sentido, o E. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Especial nº 603.616/R0, julgado sob o regime de repercussão geral, estabeleceu que, havendo “elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, é possível excepcionar a regra constitucional da inviolabilidade domiciliar:

[...] 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. [...]

(STF; Tribunal Pleno; RE 603.616/R0; Relator: MINISTRO GILMAR MENDES; j. 05.11.2015).

Por certo, “fundadas razões” e “justa causa” são conceitos jurídicos indeterminados, de modo que a leitura do voto do Ministro Relator é de grande valia para compreender quais fatos caracterizam a “justa causa”:

[...] A busca foi realizada sem mandado judicial. No entanto, havia fundadas razões para suspeitar que o recorrente estava em situação de flagrante delito quanto ao crime de tráfico de drogas. O acórdão recorrido assenta que o investigado e Reinaldo Campanha eram suspeitos de transportar drogas. Reinaldo dirigia caminhão de propriedade do recorrente. A polícia já havia monitorado encontros de ambos. Em 20.4.2007, Reinaldo partiu da casa do recorrente Paulo Roberto dirigindo caminhão que, posteriormente, foi interceptado. Inspecionado o veículo, foram localizados 23,421 kg (vinte e três quilos, quatrocentos e vinte e um gramas) de cocaína. Após a prisão, Reinaldo teria confirmado receber a droga de Paulo Roberto. Na sequência, os policiais foram à residência de Paulo Roberto e ingressaram na casa e em seu terreno sem autorização. Ao revistarem o veículo estacionado na garagem, localizaram os 8,542 kg (oito quilos, quinhentos e quarenta e dois gramas) de cocaína adicionais. O ingresso forçado na casa estava amparado no acompanhamento prévio e nas declarações do flagrado Reinaldo, elementos suficientes para indicar fundadas razões de que Paulo Roberto estivesse cometendo o crime de tráfico de drogas. [...]

Pertinente transcrever, ainda, a manifestação do Ministro Celso de Mello, durante os debates:

É fundamental que exista causa provável, cuja ocorrência legitimará o ingresso de terceiros em residência alheia, ainda que “invito domino”, desde que, por óbvio, registre-se qualquer das situações excepcionais a que alude o inciso XI do art. 5º da Constituição.

Portanto, diante desse contexto, apresentando-se demonstradas, com robustez, a materialidade e a autoria da figura disposta no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, e ausentes excludentes da ilicitude e da culpabilidade, de rigor se impõe a condenação do réu.

Por consequência, inviável a desclassificação do fato para o descrito no artigo 28 da Lei de Drogas.

Em consonância com o artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo, à luz da Folha de Antecedentes (fls. 48/49) e Certidão carreadas (fls. 50/51), que o réu não ostenta condenação definitiva.

Não há, nos autos, informações relevantes sobre sua personalidade e conduta social, tampouco indícios de que estas tenham influenciado no propósito criminoso.

Sua culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade de sua conduta, é elevada para esta modalidade de crime, haja vista a natureza especialmente nociva do “crack” e a significativa quantidade de entorpecentes apreendidos.

Nesse raciocínio, fixo a pena base em patamar superior ao mínimo, aplicando-lhe a majoração de 1/6 (um sexto), ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por falta de elementos sobre a capacidade financeira do réu, o valor unitário do dia-multa deve ser fixado no mínimo legal.

Na segunda etapa da dosagem, verifico que inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase da dosimetria, de rigor se impõe o reconhecimento da causa de

diminuição de pena capitulada no artigo 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, posto que o réu é tecnicamente primário e não há prova de que integre organização criminosa, tampouco de que se dedique à atividade ilícita.

De outro vértice, não é o caso de se aplicar a fração máxima de redução, haja vista a significativa quantidade de entorpecente apreendido e a natureza especialmente nociva do "crack".

Nesse sentido:

"Na falta de indicação pelo legislador de balizas para o quantum de redução, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição do patamar de redução ou, até mesmo, para impedir a aplicação da minorante quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. Precedentes".

(STJ; HC 364113/SP; Quinta Turma; Ministro Ribeiro Dantas; j. 04.10.2016)."

Nesse raciocínio, tais elementos, somado ao contexto dos autos, determinam a redução intermediária da pena em 1/3 (um terço), passando-a para 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa.

Por sua vez, quanto ao regime prisional, tendo em vista o quantum da pena imposta e a recente decisão do C. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus nº 596.603 - SP, de relatoria do i. Ministro Rogerio Schietti Cruz (item 21.4.: "Aos condenados que atualmente cumprem pena por crime de tráfico privilegiado, em que se reconhecem todas as circunstâncias como favoráveis, e aos que vierem a ser sancionados por tal ilicitude (mesmas circunstâncias fáticas), determinar que não se imponha - devendo haver pronta correção aos já sentenciados - o regime inicial fechado de cumprimento da pena"), imperioso, observado os parâmetros dispostos no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, o estabelecimento do regime aberto.

Descabida, de outro lado, implicando alteração de entendimento pessoal pretérito, a pretendida substituição da pena privativa de liberdade imposta por restritiva de direitos, simplesmente porque tal benefício, à vista das circunstâncias do caso e, especialmente, da nocividade da conduta praticada, não se apresenta como medida suficiente e socialmente recomendável (artigo 44, inciso III, do Código Penal).

Como é sabido, o tráfico, independentemente de sua modalidade, envolve pessoas que disseminam um vício nefasto, movidas pela cobiça e pelo enriquecimento ilícito, constituindo, ainda, delito que fomenta a maior parte dos crimes patrimoniais, notadamente os mais graves, de forma a exigir, por parte das Autoridades constituídas, resposta penal firme e a altura do mal que causam à sociedade e famílias.

Nesse aspecto, por sua propriedade, transcrevo parte da decisão proferida pelo eminente Desembargador PINHEIRO FRANCO, ex Presidente de nossa honrada Corte de Justiça Bandeirante, nos autos da Revisão Criminal nº 0008791-07.2013.8.26.0000, julgada em 27 de março de 2014: "A atividade do traficante, indivíduo sem escrúpulos, é tão perniciosa para a sociedade, destruindo o cidadão e sua família para o exercício do comércio ilícito, que fica até mesmo difícil imaginar uma pena substitutiva para ser aplicada, se fosse caso. Ademais, condutas como a do acusado disseminam o vício, criando toda sorte de problemas, desde os mais óbvios, de saúde pública, até aqueles que constituem reflexo da atividade, vez que a prática do tráfico fomenta a ocorrência de diversos outros crimes graves, demandando uma enérgica e séria reação do Estado, até como fator profilático".

O mesmo entendimento é adotado, atualmente, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NOCIVIDADE DOS ENTORPECENTES. FIXAÇÃO DO REGIME INTERMEDIÁRIO JUSTIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE ORDEM OBJETIVA PREVISTO NO ART. 44, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL - CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ. 2. Firme o entendimento de que nos delitos previstos na Lei de Drogas, a fixação do regime prisional deve observar a regra imposta no art. 33, § 2º do Código Penal - CP em conjunto com o art. 42, da Lei n. 11.343/2006, que determina a consideração, preponderantemente, da natureza e quantidade da droga. 3. Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direito, nos termos do artigo 44, inc. III, do CP, devido à variedade, quantidade e natureza lesiva dos entorpecentes apreendidos (cocaína e crack). 4. Agravo regimental desprovido".

(negritei)

(STJ - AgRg no AREsp 1674067/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/06/2020).

Na mesma toada, é o posicionamento atual de nossa E. Corte de Justiça Paulista, que abaixo transcrevo, com destaques:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES - TRÁFICO PRIVILEGIADO - ALEGA CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO COM O JULGAMENTO DO HC Nº 596.603/SP, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS - FAZ-SE NECESSÁRIA A ADEQUAÇÃO DO JULGADO - CONFORME DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FICOU VEDADA A APLICAÇÃO DE REGIME FECHADO AO TRÁFICO PRIVILEGIADO, QUANDO O RÉU É APENADO NO MÍNIMO LEGAL - SUBSISTE A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENAS ALTERNATIVAS, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO - EMBARGOS ACOLHIDOS PARA FIXAR REGIME ABERTO PARA OS EMBARGANTES, MANTENDO-SE, NO MAIS, O V. ACÓRDÃO."

(Embargos de Declaração Criminal 1506211-61.2019.8.26.0050; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Relator (a): EUVALDO CHAIB; Data do Julgamento: 25/11/2020).

"EMBARGOS INFRINGENTES - Tráfico de drogas - Pretensão à fixação de regime inicial aberto e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do voto vencido - Parcial acolhimento - Tráfico de drogas privilegiado - Natureza hedionda afastada - Substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Não cabimento - Benesse que não se mostra suficiente para reprovação e prevenção do crime - Regime inicial aberto - Possibilidade - Quantidade compatível à determinação do HC nº 596.603 do C. STJ - Embargos Infringentes parcialmente acolhidos."

(Embargos Infringentes e de Nulidade 0010198-32.2019.8.26.0196; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Relator (a): ROBERTO PORTO; Data do Julgamento: 24/11/2020).

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição - Inviável a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 - Aplicação do redutor inserto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06 - Regime aberto - Possibilidade - Determinação proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 596.603/SP - Impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos - Recurso ministerial parcialmente provido."

(Apelação Criminal 1500230-13.2019.8.26.0580; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Relator (a): RICARDO SALE JÚNIOR; Data do Julgamento: 11/11/2020).

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia (fls. 02/04), para CONDENAR o réu VINICIUS AMARAL DOS SANTOS, qualificado a fls. 21, nascido aos 05.12.2000, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Cleide Amaral e Claudionor Vieira dos Santos, RG nº 57.178.144/SP, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput" e § 4º, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena de reclusão de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, calculado o dia-multa no mínimo legal, a ser corrigido a partir da data dos fatos (18.01.22).

Ausentes, à luz do contexto dos autos, os fundamentos para decretação da prisão preventiva, concedo ao condenado o direito de recorrer em liberdade.

Expeça-se, imediatamente, alvará de soltura clausulado.

Tratando-se de pessoa desprovida de recursos, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Indicando as circunstâncias do fato que a balança e o dinheiro apreendidos (Auto a fls. 17/18 e depósito judicial a fls. 119) possuem relação com o tráfico de drogas, declaro o perdimento de ambos em favor da União (art. 63 da Lei nº 11.343/06).

Por não vislumbrar correlação com a prática delitiva (fls. 153/159), autorizo, após o trânsito em julgado, a restituição do aparelho celular apreendido ao réu.

Anoto, para controle, que o réu está assistido por Defensor Público.

Transitada em julgado, expeça-se guia de recolhimento, intime-se o réu para pagamento da multa, oficie-se para reversão da balança e do dinheiro à União, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral e, oportunamente, arquivem-se os autos.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Presidente Prudente, 24 de junho de 2022.

CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO
Juíza de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA